

1500263-84.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/05/2022

... como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico".

No mesmo sentido é o entendimento do i. Des. Sérgio Ribas (Apelação nº 0001509-

68.2017.8.26.0616 - 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep

08735-270

1500263-84.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500263-84.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alberto Jose da Silva Junior

Juiz de Direito: Dr. Davi de Castro Pereira Rio

VISTOS.

ALBERTO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas cominadas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo relata a denúncia, no dia 30 de janeiro de 2022, por volta das 13hs40min, na Rua Capitão Eurico José de Oliveira, nº 54, Mogi das Cruzes/SP, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia, 45 (quarenta e cinco) invólucros contendo 84,51g de cocaína, substância entorpecente listada na Portaria nº 344/1998, SVS/MS, Lista F1, (Lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil).

Recebida a denúncia (fls. 136/137), o réu foi regularmente citado (fls. 168) e apresentou resposta escrita à acusação às fls. 172.

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 197).

Encerrada a fase de instrução, a i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação do acusado, sustentando a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

A Defesa do acusado apresentou alegações finais às fls. 211/223, oportunidade em que pleiteou a absolvição do réu, alegando a inexistência de prova suficiente nos autos para ensejar a condenação. Subsidiariamente, pleiteou a ilegalidade da prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, a fixação da pena-base no mínimo legal, a imposição de regime mais brando para início de cumprimento de pena, o reconhecimento da detração penal, bem como o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, passo a apreciar a preliminar ao mérito aduzida pela defesa do acusado em alegações finais.

A alegação de nulidade não comporta acolhimento.

Neste ponto, destaco que não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão efetuada.

Com efeito, os guardas civis abordaram o acusado após ele ter saído correndo dispensando no chão uma mochila contendo entorpecente, caracterizando estado de flagrância, de modo que a prisão encontra respaldo no artigo 301 do Código de Processo Penal.

Destaco que não há qualquer óbice à realização de prisões em flagrante por guardas municipais.

Chegaria a ser surreal a ideia de que, qualquer indivíduo, ao visualizar a ocorrência de um crime, pudesse efetuar a prisão em flagrante, mas que guardas civis assim não pudessem agir.

A respeito da legalidade da prisão em flagrante por guardas municipais, cumpre transcrever parte do acórdão da lavra do i. des. Lauro Mens de Mello, que de maneira brilhante, como de costume, esgota o tema: "Importante discutir para que se evite eventual alegação acerca do poder de polícia dos guardas civis. O artigo 144, § 8º, da Constituição Federal preceitua que: 'A segurança pública, dever do Estado, direto e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: § 8º - Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei'. Logo se verifica que a Constituição Federal não retira dos membros da Guarda Civil Municipal a condição de agentes de autoridade, legitimados a praticar atos de defesa à sociedade, inclusive em situações análogas às da espécie, qual seja, prender em flagrante e acompanhar a mercancia de drogas. Ademais, o Estatuto dos Guardas municipais (Lei nº 13.022/14) trata da possibilidade de patrulhamento preventivo (artigo 3º, III) e da colaboração integrada com os demais órgãos de segurança pública (artigo 5º, IV). Portanto, lhes foi conferido poder de polícia, o que legitima tal atuação. Neste sentido é inclusive o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 'Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as

Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ'. Assim, não há que se falar em ilicitude da prisão efetuada pelos guardas municipais, vez que estavam corretamente cumprindo com seu dever legal. 'Last but not least', estando o réu em situação de flagrância, possível sua prisão por qualquer do povo, por óbvio, também o guarda municipal." (TJSP; Apelação Criminal 1516484-50.2019.8.26.0228; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020).

Outrossim, especificamente quanto aos depoimentos dos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social.

Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

Por tais motivos, rejeito a alegação de nulidade.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 08/13, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, pelo laudo de constatação provisória de fls. 20/23 e 185/187, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 188/190, pelo laudo pericial de fls. 193/196, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo.

A autoria do delito é incontroversa.

O acusado Alberto José da Silva Júnior disse que estava no interior de um ônibus indo para a casa de sua avó quando percebeu que um policial o olhava muito, de modo que o indagou por qual motivo ele não parava de olhar. Contou que o policial teria dito que quando descesse do ônibus estaria preso, razão pela qual quando o ônibus parou desceu correndo. Disse que foi abordado por outro policial e que em suas mãos tinha apenas uma garrafa de vinho. Esclareceu que não conhecia os policiais e que ostenta condenação por roubo.

No caso em tela, as provas existentes sobejamente comprovam os fatos imputados.

Os guardas civis relataram em detalhes os fatos, não deixando dúvidas quanto à imputação irrogada contra o acusado.

O guarda civil Eric Aparecido da Silva disse que estava no seu trajeto para o trabalho no interior de um ônibus quando o acusado passou a dizer que era do "crime" e do "partido" e que já tinha ficado preso por dez anos. Contou que, em dado momento, o acusado se aproximou perguntando se o depoente era policial, de modo que pediu a ele para se manter calmo. Contou que em determinado momento o acusado desceu do ônibus e saiu correndo, dispensando uma sacola, porém, como seu colega de trabalho o esperava para dar-lhe uma carona, conseguiram perseguir o acusado e abordá-lo. Disse que, em revista pessoal, localizou em poder do acusado cinco invólucros de cocaína e na sacola por ele dispensada outras porções de cocaína semelhantes as apreendidas com ele. Contou que o acusado ora dizia que a

droga era para seu consumo pessoal e ora que precisava de dinheiro. Disse ter encaminhado o acusado ao distrito policial, local em que se constatou que o acusado era egresso do sistema prisional. Contou que havia outros passageiros no ônibus que não foram arrolados como testemunhas, não podendo dizer se no interior do ônibus havia câmeras de segurança.

No mesmo sentido foi o depoimento do guarda civil Hugo Daniel Silva Coutinho. Este relatou que aguardava a testemunha Eric quando parou o ônibus que ele utilizava, descendo do veículo o acusado que passou a correr, dispensando uma sacola. Disse que, na companhia de seu amigo Eric, foram ao encalço do acusado, conseguindo detê-lo que portava no bolso da calça cinco invólucros contendo cocaína e um celular e na sacola por ele dispensada mais de trinta porções de cocaína semelhantes as apreendidas com ele. Disse ter encaminhado o acusado ao distrito policial, local em que se constatou que ele era egresso do sistema prisional. Por fim, contou não ter conduzido testemunhas ao distrito policial.

Deveras, nada desautoriza o depoimento prestado pelos guardas civis, no caso concreto.

Ao contrário, as testemunhas, ouvidas em juízo e na fase extraprocessual, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Destaco, ademais, que não há motivos para distinguir a validade do depoimento de guardas civis das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário.

Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander:

“Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito.” (Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander).”

In casu, as provas produzidas em Juízo são firmes e seguras ao apontar o acusado como sendo autor do delito de tráfico de drogas.

A versão apresentada pelo réu não convence, sendo claro que a narrativa possui mero caráter exculpatório, além de não encontrar ressonância nas provas carreadas aos autos.

Além do mais, os guardas civis foram firmes e seguros ao afirmarem que o acusado tentou empreender fuga, momento em que visualizaram o acusado dispensando uma sacola que em seu interior havia grande quantidade de entorpecente.

Com efeito, não há como se crer que guardas civis, no exercício regular de suas funções, sem qualquer motivo concreto, fosse prender o acusado e acusá-lo falsamente do crime.

Nesse sentido, o relato firme e convincente dos guardas civis, os quais merecem integral credibilidade, haja vista inexistir, nos autos, qualquer elemento de prova apto a infirmar sua força de convicção, observando-se que pequenas contradições são insitas à prova oral e não a maculam.

Destaco, ainda, que as provas são seguras nesse sentido e ficaram comprovadas, não só pela situação flagrancial retratada nos autos a quantidade do entorpecente apreendido, conforme auto de exibição e apreensão, a forma pelo qual foi detido, evidenciando, assim, a prática de mercancia ilícita.

Ressalto que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, basta a finalidade de guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, para caracterizar o crime em questão.

Assim, no caso em tela, fica afastada a tese de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, uma vez que os elementos são claros no sentido de que o réu praticava o comércio de drogas.

Além disso, o fato de ser usuário de entorpecente, por si só, não altera o conjunto probatório, já que é notório o fato de que muitos usuários acabam comercializando entorpecentes justamente para manter o vício.

Dessa forma, provadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo, então, à fixação da pena.

Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, o qual indica todos os parâmetros para a fixação da pena-base, levando-se em conta os péssimos antecedentes criminais que ostenta (fls. 87/93 – autos nº 0000591-68.2008.8.26.0361, 0002372-91.2009.8.26.0361 e 0002811-29.2014.8.26.0361), fixo a pena-base aumentada em um terço, vale dizer, pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 87/93 e conforme F.A. de fls. 94/11, dando conta de sua condenação no processo nº 0014048-31.2012.8.26.0361 da 2ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes, com término do cumprimento da pena em 19 de maio de 2026), razão pela qual aumento a pena em um sexto, alcançando a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Não há outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico a impossibilidade de seu reconhecimento, tendo em vista tratar-se de réus reincidente e possuidor de maus antecedentes.

Assim, como se vê, não se trata de traficante eventual ou de pequeno traficante, a justificar a redução da pena como se pode ver.

Nesse sentido, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra do i. Desembargador Geraldo Wholers (Apelação nº 0427092-39.2010.8.26.0000 - 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo):

“O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4o, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente “não se dedique às atividades

criminosas". Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico".

No mesmo sentido é o entendimento do i. Des. Sérgio Ribas (Apelação nº 0001509-68.2017.8.26.0616 – 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo):

"Não se pode olvidar, visa a lei, dentre outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e natureza da droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir apenas pequeno número de pessoas, e com menor grau de devastação, punindo, em contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam maior risco à sociedade, pelas razões inversas".

Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Ressalto que não há qualquer inconstitucionalidade no tipo legal do tráfico, ou mesmo em seu preceito secundário, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece um maior rigor contra os crimes hediondos e aos equiparados a estes.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, sendo o regime fechado o único compatível para atender as finalidades de prevenção e repressão da pena.

Neste ponto, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra o i. Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan (Apelação nº 0014063-92.2015 – 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo):

"O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente. Outro regime seria insuficiente para a reprovação de tráfico dessa monta. Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui, sendo exemplo disso que 70% dos processos em julgamento nas sessões ordinárias dessa E. Câmara, sempre em número superior a 500 feitos, são referentes a tráfico de drogas. Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado para o traficante. Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios".

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força do art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como pelo fato de que não estão preenchidos os requisitos objetivos do art. 44 do CP.

Indefiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, preso em flagrante delito, permanece as circunstâncias que autorizaram a manutenção da

custódia cautelar.

Ademais, não há elementos para formar a convicção de que atenderia ao futuro chamado judicial se fosse, agora, colocado em liberdade, mormente após a condenação.

Destarte, a manutenção da custódia faz-se necessária para aplicação da lei penal e assegurar a manutenção da ordem pública, que ficaria visivelmente abalada caso fosse colocado em liberdade.

Ressalto que estão presentes todas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado às fls. 112/116.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar ALBERTO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O ao cumprimento de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática delituosa.

Indefiro o recurso em liberdade ao acusado, ante as razões expostas.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Destaco ser incabível o reconhecimento da detração penal, uma vez que se trata de matéria afeta à execução criminal, sede natural para análise dos requisitos exigidos pela lei.

Por fim, determino a destruição do objeto apreendido, bem como a incineração dos entorpecentes.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 01 de maio de 2022.